

1500412-49.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092166/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 24073510 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2092166 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME VINICIUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500412-49.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500412-49.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092166/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 24073510 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2092166 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME VINICIUS FRANÇA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

GUILHERME VINICIUS FRANÇA foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 04 de abril de 2.022, por volta das 15h30, na rua Luis Berro, 2-38, Jardim Country Club e na rua São Tomé, 1-63, Jardim Redentor, nesta cidade, tinha em depósito, para fins de tráfico, 296,77 gramas de crack e 342,86 gramas de cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado (fls. 114), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 129/132.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 22 de junho de 2.022 (fls. 139/141). Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 211 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 221/228).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 232/237, alegando que: 1)- preliminarmente, as provas são nulas por violação de domicílio; 2)- as provas são frágeis; 3)- o aumento da pena base não pode superar a fração de um sexto, pois a única circunstância desfavorável é a quantidade de droga; 4)- deve ser reconhecida a atenuante da confissão, compensando-se com a agravante da reincidência. Pediu o reconhecimento da nulidade da prova e, alternativamente, a exasperação da pena base em um sexto e a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão de fls. 17/18 (R\$ 2.225,00; um saco contendo centenas de microtubos de plástico vazios; três balanças; um veículo; e pelo laudo pericial de fls. 73/78 (oitenta porções de crack com peso de 16,24 gramas, uma porção de crack com peso de 280,53 gramas, cinco porções de cocaína com peso de 1,63 gramas e uma porção de 248,11 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Em juízo, a testemunha Valeria Isabel dos Santos, investigadora de polícia, afirmou ter recebido informação de que o réu estaria abastecendo um ponto de drogas no bairro Geisel. Iniciou observações para captar a dinâmica de sua conduta. Percebeu que ele saía de uma casa situada no bairro Tangarás, no período da tarde, sempre após o almoço, e se deslocava até a residência de sua mãe, no bairro Redentor, onde permanecia algum tempo, para após se dirigir a ponto de venda de drogas no bairro Geisel. Na data do fato, estava em observação na casa no bairro Tangarás e viu que o acusado saiu do imóvel com um volume em sua cintura. Ele se utilizava de uma moto para se locomover. Os policiais decidiram por efetuar a abordagem com apoio de outra equipe policial. Porém, ele foi perdido de vista no trajeto. Quando chegou na residência da genitora do acusado, percebeu que ele já havia adentrado na casa, pois sua moto estava na garagem. Ficou no local fazendo observação por certo tempo. Viu que uma moto parou e o réu fez um gesto de troca com o respectivo motorista. Tentou abordar o rapaz da moto, mas não conseguiu. Os policiais foram atrás do acusado, mas ele entrou na casa e fechou a porta. Quando os policiais ingressaram no imóvel, o réu confessou a prática do tráfico. Ele foi informado da investigação. Foi localizada grande quantidade de entorpecentes num forro, situado perto da sala. Apreendeu-se também grande quantidade de pinos para embalar drogas, mas não se recorda se foram achados naquele mesmo forro. Havia quase trezentos gramas de cocaína e mais um tablete do mesmo material. Em seguida, os policiais foram ao imóvel do bairro Tangarás e ali informaram a esposa do acusado sobre a investigação. Ela afirmou que nada havia de errado e que poderiam ingressar no imóvel. No quarto do casal, foram encontradas uma porção de crack e outras já fracionadas do mesmo entorpecente, cerca de oitenta. Acredita que ali também foi apreendido dinheiro. Como a esposa dele não foi vista nas observações praticando o tráfico, ela não foi detida. Na casa do Jardim Redentor, acredita que somente residia a mãe do réu. Não sabe se mais alguém morava naquele imóvel. Nessa residência, havia pinos plásticos e balança de precisão. Não se recorda se tais objetos estavam juntos com a droga ou em outro cômodo. Eram dois sacos contendo pinos, que eram muitos. Na casa da rua Luiz Berro, foi também apreendida balança de precisão, mas não se recorda se havia embalagens para entorpecente. Durante as observações, viu o réu atuando através da mesma dinâmica por sete ou oito vezes. Ele ia até à casa da mãe quando ela não estava no imóvel. Informalmente, o acusado confessou o tráfico. Na data do fato, quando saiu do bairro Tangarás, o acusado foi perdido de vista pela polícia. Mas, como os policiais sabiam da dinâmica por ele utilizada, foram até o bairro Redentor e viram sua moto na garagem do imóvel. Ao

deixar a casa do bairro Tangarás, o réu tinha um volume na cintura. No imóvel do bairro Redentor, um indivíduo se aproximou de moto e recebeu algo do acusado. Pelo que se recorda, houve apreensão de dinheiro, mas não se lembra do montante. Também não se recorda se o réu ou sua esposa deu explicação para a posse do numerário. A mãe do acusado não estava em casa quando da diligência policial. Percebeu-se que a genitora trabalhava durante todo o dia. Por isso, o réu fazia uso da casa dela. Não conhecia Guilherme. Nas observações que fez, sempre estava acompanhada de algum colega. O delegado de polícia, Dr. Luís, somente se fez presente na ocasião da abordagem. Os policiais resolveram fazer a abordagem na data em questão pois houve a confirmação de que o réu se utilizaria da mesma dinâmica e porque havia pessoas disponíveis na delegacia para acompanhar a equipe. Percebeu que o réu fez um gesto de troca rápido, típico de tráfico, com o motociclista. Não foram feitas imagens da conduta do acusado. Acompanhavam-no, normalmente, a bordo de uma viatura descaracterizada. Numa ocasião, acompanharam-no de moto.

A testemunha Doutor Luiz Augusto Puccinelli, delegado de polícia, informou ter recebido denúncia a dar conta de que o réu seria o fornecedor de drogas para pontos de venda no bairro Geisel. Policiais efetuaram diligências de campo e observaram a rotina dele. O acusado saía de sua residência, na rua Luiz Berro, no bairro Tangarás, com um certo volume, parava na rua São Tomé, casa de sua mãe, a qual trabalhava durante o dia todo, preparava as drogas (cocaína e crack) e as levava a pontos de tráfico no bairro Geisel. Algumas vezes, os próprios vendedores compareciam ao imóvel da mãe do acusado para pegar entorpecente. Diante disso, os policiais tentaram uma abordagem no dia 04, quando o réu saía de sua casa com as drogas e foi perdido de vista. Solicitado o apoio, sua equipe compareceu até casa da genitora do réu e percebeu que a motocicleta dele estava na garagem. Deduziu que o acusado estava preparando a droga para a entrega e aguardou no local a saída dele da casa. Em certo momento, um indivíduo em motocicleta encostou no portão da casa. O réu saiu e lhe entregou porções de entorpecente. Em seguida, o motociclista saiu rápido com a moto. Deu ordem de parada ao réu, mas ele tentou correr rapidamente para o interior da casa. O acusado acabou abordado. Na residência, havia porções brutas de cocaína, pinos para embalar a droga e balança de precisão. O réu confessou que usava a casa de sua mãe para fracionar drogas, bem como que possuía mais entorpecente em sua residência, situada na rua Luiz Berro. Neste imóvel, havia porções brutas e fracionadas de crack, dois mil e duzentos reais em dinheiro e balança de precisão. Informações de pessoas do bairro e observações deram conta de que a mãe do réu saía pela manhã e somente retornava para casa no final da tarde. O indivíduo de moto não foi alcançado porque agiu muito rapidamente. Não foi possível nem identificá-lo. Atuou na diligência como equipe de apoio aos policiais Valéria e Eduardo. O réu não justificou a origem dos valores em dinheiro apreendidos. Não o conhecia, mas tinha informações de que ele já havia sido preso em outras duas oportunidades por tráfico. Não havia sinais de que mais pessoas morassem na casa da mãe. O acusado afirmou que tinha um quarto naquele imóvel. No entanto, no respectivo guarda-roupas, havia somente uma camisa. A droga apreendida no imóvel situado no Jardim Redentor estava no quarto. Não presenciou o encontro da droga porque ficou na sala enquanto os policiais diligenciavam nos demais cômodos. A investigação durou menos de um mês. Não foi requerido o deferimento do mandado de busca para a casa, pois os policiais presenciaram naquela data situação muito clara de prisão em flagrante, já que o réu saiu de sua residência novamente portando drogas. Em razão da urgência, dispensou-se a representação pela expedição do mandado de busca. Os investigadores já estavam elaborando o relatório. Acredita que os policiais não abordaram o réu nas observações anteriores pois não havia efetivo policial suficiente para tanto.

A testemunha Eduardo Iracio Goy, investigador de polícia, disse que o réu estava sendo investigado há cerca de três ou quatro semanas. Havia a informação de que o ele saía de sua casa e levava droga até à residência de sua mãe, onde fazia o manuseio e embalagem. Os policiais diligenciaram e verificaram que o réu realmente fazia esse trajeto algumas vezes. Em certas ocasiões, ele foi visto servindo pessoas em frente ao imóvel da mãe. Na data do fato, a dinâmica foi a mesma. Antes de as equipes de apoio chegarem, viu o réu entregando algo a um indivíduo. Quando

ele percebeu a aproximação da polícia, ingressou no imóvel. Os policiais entraram em seguida. Questionado sobre entorpecente, o réu inicialmente negou, mas depois apontou que o material estava no forro da casa. No local apontado, foram encontradas porções de cocaína, bem como pinos vazios. Não se lembra se foram também achadas balanças. O réu confessou que, em sua residência, no bairro Tangarás, também havia droga. Os policiais rumaram para tal imóvel e fizeram contato com a esposa do acusado. Ela, assustada com a notícia de que o marido houvera sido detido por tráfico, autorizou que os policiais ali adentrassem. No guarda roupas, foram encontradas porções brutas de crack e várias já prontas para venda. Também havia balança no local. Ao todo, foram apreendidas três balanças. No mesmo imóvel, foram apreendidos cerca de dois mil reais, em várias notas. O acusado comentou que o numerário era fruto de uma venda de algo, salvo engano. Observou o réu dirigindo-se da casa dele para a de sua mãe por cerca de três vezes, durante o período da tarde. Em tais ocasiões, a mãe não estava no imóvel, pois parece que trabalhava. A esposa dele não sabia de seu envolvimento com tráfico. Na data do fato, estava na equipe de Valéria. Realizou aproximadamente cinco campanhas. Soube que o réu apenas abastecia ponto de venda de drogas. Não identificou de onde ele pegava o entorpecente para depois repassar. Nas três ocasiões em que percebeu a dinâmica citada, acompanhou Guilherme, a bordo de um veículo. Não fez imagens do que foi visualizado. Como havia um volume na parte da frente da blusa, acreditou que ele estaria a carregar droga. Em uma outra oportunidade, viu uma pessoa buscando entorpecente na casa da mãe do réu. Na data do fato, a intenção da polícia era detê-lo antes de ele chegar no imóvel da genitora, mas não deu tempo. Os policiais permaneceram observando e viram o réu fazer uma entrega, tendo então convicção de que estaria com drogas no imóvel. Quando o avistou fazendo uma entrega anteriormente, estava apenas em uma equipe e, por isso, não foi possível abordá-lo. Na primeira ocasião, teve mais uma suspeita, em razão da rapidez dos fatos. Entre a primeira e a segunda oportunidade, passou-se uma semana ou mais. Os investigadores até pensaram em formular pedido de busca mas, antes, julgaram melhor tentar a abordagem durante o trajeto.

A testemunha Giele Trevizan afirmou conhecer o réu, porque é manicure e atende a esposa dele há dois ou três anos. Não reside perto do acusado. Não presenciou a prisão dele. O acusado trabalhava. Seu marido o ajudou a fazer bicos de pintura e funilaria. O réu morava com a mãe dele. A esposa morava na casa da genitora dela. Os dois não moravam juntos. Não sabe dizer de quem é o endereço do bairro Tangarás, pois a esposa do acusado ia até seu estabelecimento. A mãe dele reside no bairro Redentor. Não sabe onde se situa a residência da genitora da esposa. Não sabe dizer a origem do dinheiro apreendido em poder do réu. Nunca viu o casal vivendo com luxo.

A testemunha Rayan Borges dos Santos Gonçalves disse conhecer o acusado desde pequeno. Foram criados juntos. Soube da prisão dele e ficou surpreso. Sempre trabalhou com o réu em bicos de pintor e pedreiro. Giele é sua tia. Não sabe a origem do dinheiro apreendido em poder do acusado. Ele morava com a mãe no bairro Jardim Redentor. Ele tinha uma namorada e a visitava todo fim de semana, na casa dela. A namorada morava com a mãe no bairro José Regino. Não sabe quem mora na casa do bairro Tangarás. O réu era usuário de drogas. Ninguém comentou sobre ele praticar o tráfico. O acusado sempre reclamava da falta de dinheiro e que tinha dificuldades.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que a droga foi encontrada pelos policiais na residência de sua mãe. Levou-os, em seguida, até a casa de sua esposa, onde havia mais entorpecente. Cooperou com a diligência policial para tudo terminar numa boa. Guardava a droga e recebia pagamentos semanais. Recebia para guardar a droga e, às vezes, entregá-la a terceiros, que iam até o endereço. O dinheiro apreendido era proveniente do pagamento pela guarda do entorpecente. O "rapaz" lhe pagava parte em dinheiro e parte em droga para seu consumo. O dono do entorpecente ligava de vez em quando, informando-lhe que alguém iria buscá-lo. Isso ocorria uma vez só na semana. A distância entre as duas casas poderia ser percorrida, de moto, em cerca de dez minutos. No dia da prisão, estava na residência de sua mãe. Após vinte minutos, os policiais arrombaram a porta e entraram. Havia feito uma entrega de droga a um

rapaz naquela data. Não viu policial nenhum antes de entrar no imóvel após ter feito a entrega. Os policiais invadiram a casa após vinte minutos da entrega. Não fugiu deles em nenhum momento. Os policiais não sabiam o endereço da casa de sua namorada. Eles lhe perguntaram se havia mais droga. Respondeu-lhes que tinha mais material ilícito em uma casa, rumo à qual os conduziu. Não estava conseguindo emprego. Caiu nesse "laço" de estar guardando droga. O rapaz lhe ofereceu dinheiro para guardar e, às vezes, entregar entorpecente. Acabou aceitando, por estar passando necessidades e não conseguir emprego nas oficinas de veículos. Às vezes, fazia serviço de repintura ou polimento de carros. Recebia mil reais por semana e vinte gramas de droga para seu consumo, a fim de guardar o material. Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

A alegação de que teria ocorrido violação de domicílio não merece prosperar. A investigadora Valéria narrou ter visto o acusado dirigir-se de sua casa para a residência de sua mãe por aproximadamente sete ou oito vezes, durante a tarde, período em que a genitora não estava em seu imóvel.

O investigador Eduardo, por sua vez, disse ter presenciado a mesma dinâmica por três vezes, nas cerca de cinco campanhas que realizou.

Ainda de acordo com a prova oral, o réu foi visto, em data anterior, fazendo uma entrega em frente da casa de sua mãe.

Outrossim, as testemunhas de acusação também disseram ter visto um volume na cintura do acusado, durante o trajeto que ele fazia entre as duas casas.

E, na iminência da prisão, o réu entregou algo a terceiro (ele próprio confirmou, no interrogatório judicial, que a transação envolveu entorpecente) e, assim que notou a aproximação dos policiais, correu para o interior da casa de sua mãe, apesar de o delegado de polícia Doutor Luís Augusto Pucinelli lhe ter dado ordem de parada.

Diante de todo esse quadro, não paira dúvida de que havia situação de flagrante delito, isto é, podia-se entender que o réu estava guardando drogas na sua casa e na de sua mãe, o que motivou a atuação da polícia no interior do segundo imóvel desde logo.

Acresça-se que, se os policiais dali se retirassem para obter mandado de busca e apreensão ou mesmo se permanecessem em frente ao imóvel mas retardassem a diligência, certamente o réu, que já os tinha visto e inclusive notado que eles observaram a entrega de entorpecente que houvera acabado de fazer, iria dissipar o material ilícito que havia na residência de sua mãe.

Ainda que não pudesse sair do imóvel na posse do material ante a permanência de policiais na vigilância, o acusado bem poderia jogá-lo em vaso sanitário ou então ocultá-los em local desconhecido e de difícil acesso no próprio imóvel, que ele deveria conhecer bem.

Veja-se, ademais, que não havia uma razão plausível para que o réu rotineiramente fosse, no mesmo horário, para a casa da genitora, mesmo porque, ainda em consonância com a prova oral, ela não ficava ali no período de permanência de Guilherme.

Cabe, então, a pergunta: se o acusado não ia visitar a mãe, o que poderia estar fazendo no imóvel dela, frequentemente ?

Daí, pois, mais um fator a embasar a fundada suspeita de prática criminosa na casa. Por outro lado, a circunstância de a polícia civil não ter solicitado mandado de busca e apreensão perante a Justiça, como, reconhece-se, costuma fazer, não elide a constitucionalidade da diligência.

Afinal, como foi afirmado pelo policial civil Eduardo, a intenção era abordar o acusado durante o trajeto por ele percorrido entre sua casa e a de sua mãe.

A cautela informada era plenamente justificável porque, assim agindo, a polícia não teria que adentrar forçadamente em moradia alheia, com todo constrangimento e questionamento que isto via de regra suscita.

Já o fato de o réu não ter sido abordado por ocasião da primeira oportunidade em que foi visto realizando uma entrega na frente da casa de sua mãe não tem, igualmente, o condão de ensejar suspeita sobre a diligência da polícia civil.

É que, naquele momento inicial, poder-se-ia ainda ter alguma dúvida da real motivação do comportamento do acusado.

Aliás, os investigadores de polícia foram até prudentes em retardar o momento da abordagem.

Veja-se que, se a realizassem desde logo, correriam mais ainda o risco de que a atenta defesa viesse a alegar que não havia situação de flagrante delito hábil a justificar a abordagem.

Ainda, como explicado pelos policiais, a não realização da diligência naquele primeiro instante se deu também porque não havia efetivo suficiente para que ela pudesse ser bem sucedida.

De resto, destaque-se que, como afirmado por Valéria e Eduardo em juízo, e confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório, ele próprio afirmou aos policiais que, em sua casa ou na de sua namorada, havia mais entorpecente. Continuava a existir, portanto, situação de flagrante delito a justificar que a polícia adentrasse igualmente no segundo imóvel, sem contar que, segundo os mesmos investigadores, a esposa do réu autorizou a entrada no local.

Enfim, como é sabido, a conduta de ter droga em depósito para fins de tráfico é delito permanente, autorizando, portanto, a entrada na residência do agente, ainda que sem mandado ou autorização do morador.

Assim já entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

"Verifica-se que o V. Acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, que entende ser permanente o crime de tráfico de drogas - no modalidade guardar ou ter em depósito-, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator. Incide, portanto, no caso, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal." (RHC nº 91.497/SP.STJ. Relator: Ministro Félix Fischer)

Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616, o STF decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é possível quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto e que indiquem que, no interior da residência, esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sendo que o controle da legalidade da justificativa dada pelos agentes policiais deve ser realizada pelo Juízo a posteriori.

No voto vencedor do julgamento mencionado, o Ministro Gilmar Mendes discorreu, primeiramente, sobre a desnecessidade do mandado judicial prévio para a violação do domicílio em casos de flagrante delito e a relação de tal diligência com os crimes permanentes: "é a própria Constituição que elenca exceções - entre elas o flagrante delito - nas quais dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa. Em crimes permanentes, o agente está permanentemente em situação de flagrante delito. Assim, seria de difícil compatibilização com a Constituição exigir controle judicial prévio para essas hipóteses." (Habeas Corpus nº 603.616/RO. STF. Relator: Ministro Gilmar Mendes)

Na sequência do voto, o Ministro indica que os policiais devem demonstrar que existe justa causa para a adoção do procedimento: "Em consequência, resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa. Ou seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio estava presente. O modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar - fundadas razões, art. 240, §1º, do CPP. Trata-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas. É amplo o leque de elementos que podem ser utilizados para satisfazer o requisito. Em suma, proponho seja fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (Habeas Corpus nº 603.616/RO. STF. Relator: Ministro Gilmar Mendes)

No caso em tela, como visto, restaram claras as fundadas razões para o proceder policial.

Prosseguindo, não deve ser olvidado que o ingresso na casa situada na rua Luiz

Berro, bairro Tangarás, pertencente ao acusado ou à mãe de sua esposa/namorada, foi legítima não somente em razão de, como visto, haver igualmente situação de flagrante delito.

Como já afirmado, a esposa/namorada autorizou que os policiais ingressassem no imóvel.

É sabido que, em data relativamente recente, no julgamento do Habeas Corpus nº 598.051, o STJ fixou parâmetros para a entrada em domicílio sem prévio mandado de busca.

Em suma, estabeleceu o STJ que, para entrada em domicílio sem mandado, devem estar presentes fundadas razões que indiquem que na residência está presente situação de flagrante delito, em consonância com o que já havia decidido o STF no julgado retro mencionado.

O STJ avançou na disciplina da matéria, estabelecendo, quando o caso, a necessidade de colheita do consentimento do morador por escrito ou mediante gravação audiovisual de tal fato, a fim de confirmar que a autorização se deu de forma livre.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. (...) 2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (...) 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. (...) 6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência – uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio – outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio. (...) 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado." (Habeas Corpus nº 598.051/SP. j em 15/03/2021. STJ. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz).

No entanto, em recente julgamento de recurso extraordinário referente aos mesmos autos, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, o Pretório Excelso entendeu que o STJ invadiu a competência legislativa ao acrescentar requisitos inexistentes aos previstos constitucionalmente para a violabilidade lícito de domicílio:

"Ocorre, entretanto, que a 6ª Turma do STJ, após aplicar o Tema 280 de Repercussão

Geral dessa Suprema Corte, foi mais longe, não só transformando o presentes habeas corpus individual em um habeas corpus coletivo, como também estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes e determinando em abstrato e com efeitos vinculantes e erga omnes a todos os órgãos da administração de segurança pública do País (...) Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o STJ, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa Suprema Corte. (...) Não bastasse isso, em segundo lugar, na presentes hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência – gravação audiovisual da anuência de entrada no local – para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa Suprema Corte no Tema 280 de Repercussão Geral. (...) Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da CF, o STJ não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. (...) Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar (...) Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, conheço do recurso extraordinário para conceder parcial provimento e anular o acórdão recorrido tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais (...)” (Recurso Extraordinário nº 1.342.077/SP. STF. j. em 02/12/2021. Relator: Min. Alexandre de Moraes)

Portanto, em virtude da decisão proferida pela Corte Suprema, não mais subsiste a necessidade de registro documental ou gravação audiovisual do consentimento do morador para o ingresso forçado em residência sem prévio mandado de busca. Assim é que, se os policiais civis, de cujas palavras não há razão para duvidar, informaram que a esposa/namorada do acusado autorizou que ingressassem no domicílio em questão, e se a defesa sequer a arrolou como testemunha para vir em juízo dizer o contrário (se não tivesse havido a autorização da moradora, certamente a defesa a teria feito depor na fase judicial para explicar a situação), conclui-se que o consentimento da dela se deu de forma voluntária e, portanto, válida. Destarte, no caso concreto, a diligência realizada pela polícia nos dois imóveis deve ser considerada lícita, haja vista que: 1)- na casa da mãe do réu, havia situação de flagrante delito; 2)- na residência do réu ou de sua namorada/esposa, havia também situação de flagrante delito, bem como consentimento válido da moradora.

Logo, não há que se falar em prova nula, por ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio.

Quanto ao tema de fundo, o fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu confessou a prática do crime em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação, mesmo porque nada indica tenha sido o réu insincero ao se autoincriminar.

Nesse sentido:

“Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário.” (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, a prática do delito foi confirmada pelo depoimentos de dois



investigadores de polícia e de um delegado de polícia, os quais flagraram o réu mantendo em depósito as drogas e os apetrechos relacionados ao tráfico, bem como realizando entrega de entorpecente a terceiros em duas ocasiões.

As afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

A tudo some-se que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a tenha em depósito (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Em suma, a condenação do réu na forma proposta na denúncia é medida de justiça.

Passa-se à aplicação da pena.

A apreensão recaiu sobre elevadas quantidades de cocaína e crack.

Trata-se, ademais, de entorpecentes cujas naturezas são especialmente prejudiciais à saúde dos usuários, e também à sociedade como um todo.

Com efeito, assiste-se a um aumento dos índices de crimes contra o patrimônio, inclusive cometidos mediante violência ou grave ameaça, praticados por agentes que querem obter recursos para adquirir tais espécies de drogas, e/ou por agentes que estão sob efeito delas.

Sendo assim, e observado o disposto no art. 42 da Lei Antidrogas, eleva-se a pena base na proporção de um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

O réu é reincidente (fls. 46 – art. 33, §4º da Lei 11.343/06).

No entanto, confessou amplamente a prática do crime.

Entende o juízo que a atenuante da confissão, por dizer respeito à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

"Por envolver a personalidade dos agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência."

(HC n. 288.910/SP, 6a Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. Em 21/10/2014) (em TJSP, Apelação n. 0020654-38.2013.8.26.0071, j. 21/05/2015).

Destarte, na segunda fase de aplicação da pena, compensa-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo-se a reprimenda no mesmo patamar anterior.

Ante o montante da pena aplicada e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Guilherme Vinicius França como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11343/2006, a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar

quinhentos e oitenta e três dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto aos pinos plásticos vazios e balanças de precisão, são bens daqueles cujas posses, por si sós, não configuram fato ilícito. Dessa forma, aguarde-se por noventa dias a contar do trânsito em julgado eventual pedido de restituição. Na inércia, os bens deverão ser doados ou inutilizados, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP.

O mesmo deve ser dito em relação ao veículo apreendido. Não restou provado que ele era utilizado de forma reiterada para o tráfico, ou que sua utilização fosse imprescindível para o cometimento do delito. Destarte, pode ele ser restituído ao proprietário, razão pela qual determina-se que se aguarde pelo mesmo prazo eventual pedido de restituição, findo o qual o bem deverá ser levado a leilão.

O réu foi preso em flagrante e permaneceu custodiado durante a instrução. Agora, condenado a cumprir pena longa, em regime inicial fechado, com maior dose de razão há de permanecer encarcerado provisoriamente, pois há o risco de que, se solto, busque se subtrair da aplicação da lei penal, sem contar a probabilidade de reiterar a prática delituosa, tendo em vista a reincidência específica. Expeça-se, pois, ofício de recomendação.

P.R.I.

Bauru, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA